

1500797-79.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 2ª. Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Indagado, disse que não viu o acusado colocando as drogas na árvore.

A testemunha PAULO RICARDO PEREIRA DE GODOY, policial militar, narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando o Copom informou que dois indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas; que o Copom passou as características da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

2ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete - SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500797-79.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500797-79.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 128/129) em face de JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 15h00, na esquina da Rua das Hortênsias com a Rua dos Ipês, Bairro Povo Feliz, nesta cidade e comarca de Tietê/SP, o acusado, supostamente, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 19 porções de cocaína, pesando aproximadamente 22,92 g (vinte e duas gramas e noventa e duas centigramas), 30 porções de crack, pesando aproximadamente 10,37 g (dez gramas e trinta e sete centigramas) e 05 porções de maconha, pesando aproximadamente 15,73 g (quinze gramas e setenta e três centigramas).

Consta da denúncia que os policiais militares receberam notícia anônima de que um indivíduo trajando blusa azul, calça azul clara e tênis branco vendia drogas no local dos fatos; que, após se dirigirem ao local apontado, encontraram o acusado, com as mesmas características descritas; que, em busca pessoal, foram encontradas três porções de cocaína e R\$ 77,00 (setenta e sete reais); que, ao lado do réu

havia uma sacola, com as demais porções apreendidas (30 porções de crack, 05 porções de maconha e 16 porções de cocaína).

O réu foi preso e autuado em flagrante de delito (fls. 01/02).

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 47/51).

Foi impetrado habeas corpus sob n.º 748.904, em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar para revogar a prisão preventiva do acusado, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 96/103). Alvará de soltura cumprido em 23/06/2022 (fls. 115/118).

A denúncia foi recebida em 04/07/2022 (fl. 131).

Devidamente citado (fl. 152), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 144/147).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 153/155), foi designada audiência de instrução e julgamento.

Julgamento do habeas corpus confirmou a liminar já concedida (fls. 177/187).

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (CPP), as partes nada requereram.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência n.º CC2584-1/2022 (fls. 03/05); termos de depoimento (fls. 07/08); auto de exibição/apreensão (fls. 09/10); auto de constatação (fls. 13/14); termo de interrogatório (fls. 15/16); relatório final (fls. 123/124); laudo toxicológico (fls. 136/139), bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (tetrahydrocannabinol e cocaína, na forma de sal e de crack) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a autoria do réu mostra-se plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha TALES ROBERT MEDEIROS DE MORAES, policial militar, disse que, na data dos fatos, receberam denúncia via Copom de que dois indivíduos estariam praticando tráfico, um com blusa azul e outro com bermuda vermelha; que foram ao local e localizaram apenas João, com a blusa azul, sentado na esquina; que realizaram a abordagem e localizaram com ele pinos de cocaína e R\$ 77,00 em notas diversas; que fizeram a apuração do local; que João estava parado ao lado/embaixo de uma árvore e, ao seu lado, na raiz da árvore, encontraram uma "sacolinha" com o restante dos entorpecentes, contendo crack e cocaína; que indagados a respeito das drogas e do dinheiro, o acusado disse que era apenas usuário e não soube informar a procedência do dinheiro. Disse que não havia mais pessoas próximas; que só havia uma parada de ônibus a alguns metros, com uma moça esperando a condução. Mencionou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Indagado, disse que não viu o acusado colocando as drogas na árvore.

A testemunha PAULO RICARDO PEREIRA DE GODOY, policial militar, narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando o Copom informou que dois indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas; que o Copom passou as características da denúncia, falando das vestes dos indivíduos; que, quando chegaram ao local, encontraram somente um indivíduo moreno, João Rafael, sentado perto de uma árvore; que, na abordagem, localizaram 3 pinos de cocaína dentro do bolso dele e um valor em dinheiro, em torno de 75 ou 77 reais; que, indagado, o acusado disse que estava passando por necessidade e traficando no local; que, ao lado da árvore, havia uma sacola com mais drogas; que havia populares passando mais longe; que uma popular próxima disse, após a finalização da ocorrência e a prisão de João Rafael, que os indivíduos estavam em dois e o outro havia saído correndo; que não se recordava de uma moça no ponto de ônibus. Declarou que, indagado o acusado sobre a droga e sobre

o dinheiro que com ele estavam, o réu teria dito que estava traficando por necessidade; no entanto, instado pela d. Promotora, diante da divergência com seu depoimento de fase policial, mencionou que não se recordava; depois, instado pela d. defesa, retomou a versão de que, pelo que se recordava, o réu tinha de fato admitido a traficância.

Interrogado, o acusado negou a prática dos fatos. Disse que era usuário de drogas e tinha ido comprar entorpecentes. Relatou que, quando foi abordado, estava de pé do lado de um “mercadinho”; que os policiais encontraram três pinos de cocaína com o acusado dentro de seu tênis; que, na época, era usuário de maconha e de cocaína; que comprou drogas de um traficante no local; que, do outro lado da rua, os policiais encontraram uma “sacolinha” contendo as outras drogas embaixo de uma árvore; que tais entorpecentes não eram seus; que entre o mercado e a árvore dá uns 2 ou 3 metros. Indagado pelo juízo, voltou atrás e disse que a árvore era do mesmo lado da rua do “mercadinho”; que não tinha visto a sacola na árvore; que o dinheiro é decorrente de um “bico” que fez como segurança. Mencionou que estava esperando para ir buscar sua enteada na escola umas 16h.

Após regular instrução processual, verifico que a prova é robusta a embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Da colheita dos depoimentos, percebe-se que o PM Tales apresentou versão clara e coerente com os elementos produzidos em fase de inquérito; ao passo que o PM Pedro não se recordava tão bem dos fatos, o que é compreensível diante da dinâmica da atividade policial, que envolve inúmeras ocorrências diárias. Embora o PM Pedro tenha apresentado confusão quanto à versão que teria sido dada informalmente pelo acusado aos policiais no momento da abordagem, extrai-se do conjunto probatório como um todo que a versão correta é a fornecida por ambos os policiais em fase pré-processual (fls. 07/08), ratificada pelo PM Tales em juízo e que, inclusive, é a mesma versão apresentada pelo acusado, qual seja, a de que alegou aos milicianos, naquele momento, que era apenas usuário de drogas.

Mesmo assim, ambos os policiais foram enfáticos ao afirmar que o acusado sentado estava embaixo da árvore, ao lado do tronco onde foi encontrada a “sacolinha” com considerável quantidade de entorpecentes (quantidade que perpassa a figura do usuário).

Assim, apesar de ter havido pequenas divergências entre os depoimentos dos policiais, essas se deram sobre aspectos laterais dos fatos, e não sobre o cerne da questão, de sorte que não enfraquecem o conjunto probatório. Nesse sentido, entende o TJSP:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000241-62.2016.8.26.0535; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021)

Ademais, não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

A versão do acusado, por sua vez, não merece guarida, pois destoa da prova dos autos e entra em contradição com a sua própria versão de autodefesa em delegacia. O réu disse, em interrogatório judicial, que estava parado em frente ao mercado, porque estava aguardando para buscar a enteada na escola; ao passo que, na delegacia, alegou que estava no local esperando um colega lhe trazer uma blusa (fls. 15/16). Ademais, o acusado disse, em juízo, que a árvore era do outro lado da rua do mercado onde estava; depois voltou atrás e disse que a árvore era do mesmo lado da via. Tais contradições, sim, são relevantes à dinâmica dos fatos, pois se referem ao motivo pelo qual o réu estava parado em ponto de venda de drogas, bem como à sua distância do local onde foram encontrados os entorpecentes. Dessa forma, entendo que a totalidade dos entorpecentes apreendidos eram de propriedade do acusado, privilegiando a versão dos policiais militares, que afirmaram, de forma coerente, que encontraram a sacola na árvore ao lado de onde estava parado o réu, sendo que o acusado vestia roupas com as mesmas características das irradiadas na denúncia anônima recebida pelo Copom. Para mais, a droga estava fracionada, em quantidade incompatível com a figura do usuário. O local era ponto de venda de drogas, onde o acusado se encontrava parado. A variedade de drogas também sinaliza a destinação ao tráfico, pois foram três os entorpecentes apreendidos. Para mais, foi apreendida, em posse do acusado, a quantia de R\$ 77,00, em notas diversas, circunstância típica a ensejar a conclusão de que o valor se trata de produto do tráfico. Todos esses elementos, acrescidos dos depoimentos colhidos em juízo, indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD). Dessa forma, tenho que a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao delito previsto no art. 33 da LD, uma vez que praticou o núcleo "trazer consigo" drogas, para fins de tráfico.

Concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que o réu é primário, com bons antecedentes, incidindo em seu favor a presunção de que ele não se dedica a atividades criminosas, uma vez que não há elementos nos autos que a infirmem. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militarará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada .2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. (HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

No caso concreto, os policiais não informaram sobre envolvimento da pessoa de João com atividades delitivas. Para o afastamento da privilegiadora, é necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem a dedicação ao crime, de tal sorte que milita a presunção em favor do réu, o que não se tem nos autos.

Quanto aos maus antecedentes socioeducativos do acusado, em que pese a jurisprudência entenda pela possibilidade de utilização de atos infracionais para afastar a minorante, essa aferição só se revela possível quando houver razoável proximidade temporal de tais atos com o crime processado, de modo a indicar uma

continuidade na dedicação das atividades criminosas pelo acusado. No caso dos autos, os apontamentos infracionais do réu se deram há mais de cinco anos, de forma que não se pode inferir que ele tenha se dedicado a atividades ilícitas durante todo esse período, justamente por ausência de notícia de que ele tenha delinquido entre 2017 e 2022.

Nesse sentido:

(...) 7. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, adotou o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos infracionais pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EResp 1.916.596/SP, Rel. p/ acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021). 8. No caso, as ações por ato infracional a que respondeu o Agravado foram por atos cometidos em 2017, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos do cometimento do delito em exame (praticado em 06/12/2021). Portanto, consoante orientação firmada no julgado acima citado, não há como extrair a necessária contemporaneidade entre os referidos atos infracionais e o fato sob julgamento, exclusivamente a partir da menção à passagem infracional, isto é, desacompanhada de qualquer análise concreta das provas atinentes à alegada dedicação às atividades criminosas. (AgRg no HC n. 744.924/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, § 4º, da LD.

A fração de diminuição será a de 2/3, por inexistirem circunstâncias que justifiquem a redução em menor patamar.

Não concorrem majorantes.

Ausentes agravantes e atenuantes. Não incide a atenuante da menoridade relativa, pois o acusado tinha 21 anos na data dos fatos.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou o delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu possui bons antecedentes (fl. 25). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade de drogas não destoa do esperado. Valoro negativamente a natureza das drogas, pois foram apreendidos três diferentes tipos de entorpecentes, incluído o crack, substância de efeitos especialmente deletérios. Por tal razão, exaspero a reprimenda em 1/6.

Fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, fica mantida a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD. Diminuo a pena em 2/3, consoante fundamentação supra.

Fica o réu definitivamente condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, pois não há circunstâncias fáticas concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, com fulcro no art. 383 do CPP, para CONDENAR JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e a 194 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois não há fato novo que justifique a decretação de preventiva (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP); ademais, a fixação do regime aberto e a substituição da pena são incompatíveis com a custódia cautelar.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produto da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o Funad (arts. 91, II, do CP, e 63 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva;
- e) oportunamente, arquivem-se.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Tiete, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA